

1500289-34.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... 4º, da Lei n. 13.654/108 (<https://www.sonoticias.com.br/opiniaio/roubo-majorado-a-celeuma-acerca-da-inconstitucionalidade-formal-do-art-4o-da-lei-136542018/>):

"Roubo majorado: a celeuma acerca da inconstitucionalidade formal do art. 4º da lei 13.654/2018.

22/05/2018 09:05

Muito tem se falado na comunidade jurídica acerca de uma suposta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

1500289-34.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500289-34.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISSON PEREIRA LISBOA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO FERRAZ DE CAMARGO LOPASSO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra o réu ALISSON PEREIRA LISBOA, qualificado a fls. 10/11, porque, no dia 01 de fevereiro de 2022, por volta das 23 horas, na Estrada Água Chata, altura do numeral 1900, bairro Água Chata, nesta cidade e comarca de Guarulhos, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, mediante emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, contra Jean Michel Guimarães Bezerra, tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta YAMAHA/XTZ250 TENERE, placas LRL7F96, avaliada em R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais), cf. auto de exibição/apreensão de fls. 16/17 e auto de avaliação de fls. 20/21, não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo o apurado, no dia dos fatos, vítima, policial militar, estava na condução de sua motocicleta de placas LRL7F96, quando, em dado momento, surgiu o acusado e seu comparsa ocupando uma moto, sem placas, os quais emparelharam ao seu lado.

Ato contínuo, ALISSON, que ocupava a garupa da moto, com uma pistola em punho anunciou o assalto dizendo: "perdeu, perdeu" (sic).

Ocorre que, para repelir a iminente e injusta agressão, o ofendido efetuou dois disparos com sua arma funcional, alvejando o acusado, tendo os criminosos realizado manobra de retorno com a moto e se evadiram.

Policiais Militares estavam em patrulhamento quando foram acionados, via Copom, para comparecerem ao Hospital Geral de Guarulhos (HGG) com o escopo de averiguarem a informação de que um indivíduo havia dado entrada no aludido nosocômio com ferimento por arma de fogo. Ali chegando, os milicianos identificaram se tratar do acuado ALISSON, que apresentava um ferimento por arma de fogo na coxa esquerda.

Em sede policial, a vítima reconheceu ALISSON como sendo um dos autores do delito, conforme acima narrado.

Denúncia recebida às fls. 55/56.

Citado pessoalmente (fl. 76), o acusado apresentou defesa preliminar (fl. 81).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 85/86).

Em audiência de instrução e julgamento, o acusado foi interrogado após a oitiva da vítima e uma testemunha (fls. 116/119).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da presente ação penal, condenando-se o réu nos exatos termos da denúncia. (fls. 116/119).

A Defesa, requereu a improcedência da ação penal, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP; tecendo teses subsidiárias em caso de condenação (fls. 116/119).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do delito e sua autoria são indúvidas.

A materialidade do delito de roubo duplamente qualificado ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/11, auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, auto de avaliação de fls. 20/21, laudo pericial de fls. 111, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa.

O acusado, em Juízo, confessou sua participação na tentativa de assalto: "Tem dezenove anos. É amasiado. Tem um filho. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Estava desempregado. Não faz uso de entorpecentes. Não tem passagem como maior de idade. Tem uma passagem como menor de idade por assalto. Cumpriu medida socioeducativa de liberdade assistida. Participou da tentativa de roubo. Está arrependido".

"A confissão judicial, – lembra a jurisprudência - sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui elemento seguríssimo de evidente prova"

(JTACRIM 93/236).

No caso em tela, a confissão do acusado encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos de prova produzidos nos autos.

A vítima Jean, ouvida em Juízo, narrou a dinâmica do assalto da mesma forma como descrita na denúncia e reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas, bem como narrou a utilização de uma arma de fogo no assalto: "É policial militar. O assalto ocorreu por volta de 23h20. Estava sozinha. Os assaltantes estavam em outra motocicleta. Estavam de capacete com a viseira aberta. Tinha acabado de acessar a via, os meliantes passaram no contrafluxo. Viu pelo retrovisor que retornaram em sua direção. Acelerou, mas foi alcançado e abordado por eles. O indivíduo na garupa anunciou o assalto e estava armado. Efetuiu dois disparos para conte-los. Os acusados retornaram. O local é ermo. Foi para sua residência e acionou a polícia. Quando estava na viatura, foi informado via COPOM que havia um indivíduo baleado no Hospital Geral. Reconheceu de pronto o acusado que estava armado na garupa da moto. Em audiência, reconhece novamente o acusado".

Em se tratando de roubo, a palavra da vítima tem sumo valor probatório, pois seu único interesse é apontar o verdadeiro acusado - ou acusados - e, aliada a outros elementos de prova, autoriza o decreto condenatório.

Assim é o entendimento:

Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância, (TACrim/SP 91/407 e 86/433)

No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. (TACrim/SP 90/362).

A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e atinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos. (94:341)

No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (RT 484:320).

Não há qualquer nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal operado pela vítima, seja na Delegacia, seja em Juízo.

As formalidades descritas no art. 226, do CPP não são essenciais, mas meras recomendações.

A propósito:

PROVA - Reconhecimento de pessoa - Inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal - Nulidade - Inocorrência - A prioridade na hipótese é a segurança, constituindo a medida de colocação de pessoa ao lado de outras, formalidade escusável, pois, ao empregar a expressão "se possível", o texto legal arredou a idéia de obrigatoriedade - Procedimento, portanto, que é recomendável e não exigível - Recurso improvido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 1.085.254-3/3 - São Paulo - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator: Rodrigo Augusto de Oliveira - 04.04.08 - M. V. - Voto n. 1.080)

RECONHECIMENTO PESSOAL - Realização sob as garantias do contraditório, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP - Nulidade - Não ocorrência: - A realização de reconhecimento pessoal sob as garantias do contraditório, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não tem o condão de acarretar a nulidade do ato. (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.387.403/2 - Ribeirão Preto - 10ª Câmara - Relator: Ricardo Feitosa - 1º. 10.2003 - V. U. (Voto nº 7.167) (TACrim - Ementário nº 50, Fevereiro/2004, pág. 28)

RECONHECIMENTO PESSOAL - Desobediência às formalidades do art. 226 do CPP - Irrelevância: - A Desobediência às formalidades do art. 226 do CPP não gera a nulidade do feito, pois o reconhecimento realizado em audiência não obedece à rigidez das normas processuais, uma vez que, na realidade, trata-se de um ato mais confirmatório do que de reconhecimento. (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Revisão nº 435.476/0 - São Paulo - 8º Grupo de Câmaras - Relator: Carlos Bonchristiano - 11.9.2003 - V. U. (Voto nº 7.487) (TACrim - Ementário nº 48, Dezembro/2003, pág. 29)

Nem se alegue eventual "inobservância" ao item 6 do Comunicado CG nº 317/2020 que dispõe: "Entendendo o magistrado sobre a necessidade da aplicação do inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, quando da comunicação da data e horário da audiência ao estabelecimento prisional, tal circunstância será informada ao estabelecimento prisional para que além do réu, se possível, sejam apresentadas duas outras pessoas que guardem com ele semelhança"..

Por primeiro, comunicado não é lei, não substitui o Código de Processo Penal nem o regulamenta. Além disso, da leitura atenta do texto por qualquer pessoa de inteligência mediana, depreende-se que o procedimento não é obrigatório. Será utilizado apenas quando o magistrado entender necessária a aplicação do art. 226, CPP, o que não é o caso, como acima esposado.

Essa celeuma fica ainda mais sem sentido no caso em tela, em que o réu confessou a tentativa de roubo perpetrada.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, tanto durante a fase inquisitorial quanto em juízo, são coesos e harmônicos.

O miliciano Daniel, ouvido em Juízo, confirmou a prisão do acusado no hospital em que foi atendido, baleado. Ele confessou o delito e confirmou a participação de um comparsa: "É policial militar. Participou da ocorrência. Foi acionado via COPOM. Estava próximo ao local da tentativa de roubo. O policial descreveu ter sido vítima de uma tentativa de roubo. Informou que acreditava ter alvejado um dos infratores. Entraram em contato com os hospitais e souberam que o réu estava no Hospital Geral de Guarulhos. Foram até o local com a vítima, que reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas. Deu voz de prisão ao réu. Em primeiro momento ele negou a autoria do crime. Depois confessou os fatos e deu o nome e endereço do comparsa. Realizaram diligências, porém não o localizaram. Não conhecia o acusado".

Seu colega de farda Rivaldo deu a mesma versão: "que na data em curso, realizava patrulhamento ostensivo, acompanhado de seu parceiro de farda, SD PM Silvestrim, quando foram acionados via COPOM para comparecerem ao Hospital Geral de Guarulhos (HGG) com o escopo de averiguarem a informação de que um indivíduo havia dado entrada no aludido nosocômio com ferimento por arma de fogo. Imediatamente os militares rumaram ao local, e lá também já se encontrava a vítima de roubo, o policial militar Jean Michel Guimarães Bezerra, que informou a equipe que por volta de 23h conduzia seu motociclo YAMAHA/XTZ250 TENERE placa LRL7F96 pela Estrada Água Chata, altura do numeral 1900, bairro Água Chata, neste município, quando dois indivíduos ocupantes de uma motocicleta sem placas emparelharam ao seu lado e o ocupante da garupa com uma pistola em punho anunciou o assalto, e para repelir a

iminente injusta agressão efetuou dois disparos com sua arma alvejando um dos criminosos. Ainda no hospital, em entrevista com o indivíduo baleado, o qual foi posteriormente identificado como sendo ALISSON PEREIRA LISBOA, e apresentava um ferimento por arma de fogo na coxa esquerda, este no primeiro momento apresentou uma versão estapafúrdia para justificar a lesão, contudo, percebendo que não conseguiria se eximir de responsabilidade por seu ato, acabou por confessar a prática delitiva, narrando em detalhes o roubo ao policial militar e detalhando sua conduta, que foi a de ocupar a garupa da motocicleta e anunciar o assalto, ademais, apresentou como motivação para cometer o crime o fato de estar passando por dificuldades financeiras. A vítima ainda no hospital reconheceu ALISSON com cem por cento de certeza como o infrator que ocupava a garupa da moto e empunhava a arma de fogo. Ante o exposto os militares proferiram voz de prisão ao ora indiciado, que ainda conduziu a equipe até a residência de seu comparsa que conduzia a moto utilizada no crime, Alexandre Borges Peixoto. No local, a equipe fez contato com sua genitora e constaram que Alexandre tampouco a motocicleta não se encontrava no local. Diante dos fatos, os policiais conduziram o investigado para este Distrito Policial e solicitaram o comparecimento da vítima para as providências de polícia judiciária pertinentes. Por derradeiro, informam que foi imprescindível o uso de algemas para condução do indiciado devido fundado receio de fuga, consoante excepcionalidade imposta pela Súmula Vinculante nº 11".

Não há motivo para desmerecer as palavras dos policiais, vez que confirmadas pelo auto de prisão em flagrante e pelo depoimento da vítima.

A propósito:

PROVA - Depoimento policial - Admissibilidade - Valor probatório analisado de conformidade com outros elementos dos autos - Materialidade e autoria comprovadas - Recurso não provido. O policial presta depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do juízo criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja - Recurso não provido. (Apelação Cível n. 41.636-0 - Santos - Câmara Especial - Relator: Alves Braga - 12.02.98 - V. U.)

Assim, diante de elementos de convicção que tais, não resta dúvida de que o proceder dos acusados amolda-se perfeitamente ao delito descrito na inicial, sendo a sua condenação medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena.

As causas especiais de aumento de pena referentes ao emprego de arma e ao concurso de agentes devem ser reconhecidas.

A circunstância do concurso de agentes restou indubitável diante da narrativa da vítima.

Embora não apreendida a arma de fogo utilizada no roubo, a vítima foi categórica ao narrar que o réu portava uma arma de fogo no momento do assalto.

A palavra firme e segura da(s) vítima(s), no delito de roubo, basta para o reconhecimento das aludidas majorantes.

A propósito:

STJ "Para a aplicação da circunstância qualificadora do uso de arma de fogo no crime de roubo, é dispensável a apreensão do artefato, mormente se sua utilização para perpetração do delito pode ser provada por outros meios, entre eles o depoimento de testemunhas ou da própria vítima" (RT 841/515)

STJ "É entendimento pacificado nesta Corte de que é dispensável a apreensão da arma

de fogo para a caracterização da causa especial de aumento, prevista no § 2º, I, do artigo 157, do CP, quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o depoimento da vítima" (RT 821/534).

Em se tratando de roubo duplamente agravado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), o aumento da reprimenda deve ser de 2/3 sobre a pena básica.

Somente é possível aplicar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, conforme estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que afirma: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."

A majorante do concurso de agentes somente pode ser considerada como circunstância do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Convém lembrar, a Lei n. 13.654/18 não padece de inconstitucionalidade formal.

Na verdade, como se verá a seguir, houve equívoco cometido na publicação do PLS 149/2015 no Diário do Senado Federal que não guardou fidelidade com aquilo que, efetivamente, foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.

Trata-se, portanto, de mera irregularidade, que não tem o condão de viciar o processo legislativo.

Ao contrário do que consta da cota ministerial, a mens legislatoris desde sempre foi no sentido de revogar a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal e tal objetivo foi, de fato, alcançado com a promulgação da Lei 13.654/2018.

Artigo publicado no site "Só Notícias" da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Procurador de Justiça (MP/MT), explica minuciosamente o equívoco cometido e que gerou toda a celeuma em torno do art. 4º, da Lei n. 13.654/108 (<https://www.sonoticias.com.br/opiniaao/roubo-majorado-a-celeuma-acerca-da-inconstitucionalidade-formal-do-art-4o-da-lei-136542018/>):

"Roubo majorado: a celeuma acerca da inconstitucionalidade formal do art. 4º da lei 13.654/2018.

22/05/2018 09:05

Muito tem se falado na comunidade jurídica acerca de uma suposta inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, designadamente no que concerne ao seu artigo 4º, o qual revogou a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Como já se sabe, o aludido diploma normativo, entre outras inovações inseridas no Estatuto Repressivo, introduziu o § 2º-A ao artigo 157 (tipo penal de roubo), aumentando a reprimenda em 2/3 (dois terços) quando o delito envolve o emprego de arma de fogo e na hipótese em que há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, no cometimento da infração. Por outro lado, o novel diploma legal, como dito, revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, que aumentava em 1/3 (um terço) a pena quando a violência ou ameaça fosse exercida com o emprego de arma (lato sensu), abrangendo, pois, todo e qualquer artefato possível de ser utilizado para a defesa ou ataque, seja ele próprio (revólver, faca, espada, etc.) ou impróprio (pedra, barra de ferro, porrete, etc.).

Contudo, na aurora da vigência da novel lei, alguns estudiosos têm apontado um suposto vício de constitucionalidade no referido documento normativo. Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento recente, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/20183. A ementa do julgado é a seguinte:

TJSP: “ROUBO SIMPLES IMPRÓPRIO TENTADO – APELAÇÃO – Pleito Ministerial de reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma (branca) – Superveniência da Lei posterior extirpando o inciso I do §2º do art. 157 do CP – RECONHECIDA a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018 – SUSPENSO o julgamento do mérito do recurso e DETERMINAÇÃO da instauração de incidente de inconstitucionalidade com remessa ao Órgão Especial para apreciação, nos termos do art. 193 e seguintes do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça”. (Apelação Criminal com Revisão nº 0022570-34.2017.8.26.0050. Quarta Câmara Criminal. Rel. Des. Edison Brandão. Data de Julgamento 08/05/2018).

Inclusive, na esteira desse entendimento, as Chefias dos Ministérios Públicos dos Estados de São Paulo (04), de Mato Grosso do Sul5 e Goiás6, recomendaram aos membros das respectivas Instituições, ainda que de maneira não vinculante, que, em sede de controle difuso, arguissem a inconstitucionalidade formal do preceito normativo que revogou a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, uma vez que, segundo argumentam, haveria afronta ao devido processo legislativo na tramitação do Projeto de Lei (PLS 149/2015) que resultou na promulgação da Lei 13.654/2018.

Em síntese, sustenta-se que no texto final do PLS 149/2015, aprovado, inicialmente, pelos senadores na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não constava qualquer dispositivo revogando a majorante do emprego de arma (lato sensu) conforme, depois, constou no artigo 4º da Lei 13.654/2018. Afirma-se, inclusive, que a CORELE (Coordenação de Redação Legislativa) do Senado Federal foi quem, indevidamente, inseriu o dispositivo no Projeto de Lei, em desacordo com aquilo que havia sido, efetivamente, aprovado pelo plenário daquela comissão, e que, posteriormente, a proposta legislativa seguiu em sua tramitação regular, levando consigo aquele vício, até sua promulgação, configurando, desse modo, a inconstitucionalidade formal por suposta afronta ao disposto no artigo 65 da Constituição Federal.

Contudo, conforme será demonstrado a seguir, a celeuma toda decorreu de um equívoco cometido pelos responsáveis pela publicação no Diário do Senado Federal da matéria aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Assim, para bem demonstrar esse lapso, importa promover aqui uma análise detalhada da tramitação do projeto de lei, a partir de consulta nos websites do Senado (07) e da Câmara Federal (08), algo que poderá ser entediante, porém necessário.

Pois bem. Consta que no dia 24/03/2015, foi protocolado o Projeto de Lei do Senado nº 149/2015, de autoria do Senador Otto Alencar, que, a um só tempo, criava, de um lado, duas novas causas de aumento de pena na hipótese de crimes de roubo, quais sejam, quando durante a prática criminosa houvesse o emprego de arma de fogo ou se fosse constatada a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 1º) e, por outro lado, revogava a majorante inculpada no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, que se referia ao roubo cuja violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma (art. 3º)9. Importante notar, prontamente, que desde a proposta inicial estava clara e taxativa a intenção de derrogar a cogitada causa de aumento de pena anteriormente prevista no Código Penal.

O projeto, que tramitou na forma do art. 91, §§ 3º a 5º do Regimento Interno do Senado Federal, depois de protocolado, foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), onde o relator, Senador Antonio Anastasia, emitiu

parecer pela aprovação da proposta (10), tal qual apresentada pelo proponente.

A matéria foi incluída na pauta da CCJ e, então, na sessão do dia 13/09/2017, após a leitura do relatório do Senador Antonio Anastasia, foi concedida vista do projeto aos Senadores Eduardo Amorim e Vanessa Grazziotin. Não houve, portanto, naquela sessão, qualquer deliberação a respeito do mérito do projeto de lei (11).

A matéria voltou à pauta da sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ocasião na qual a Senadora Simone Tebet apresentou a Emenda Aditiva nº 0112, que, a rigor, nada alterou a proposta original no ponto em que revogava a majorante insculpida no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Naquela mesma sessão, o Senador Antonio Anastasia reformulou seu relatório, acolhendo a emenda que foi proposta, e, posteriormente, o plenário da cogitada comissão aprovou¹³ o texto do Projeto de Lei – Parecer (SF) 141/2017¹⁴ –, tal qual formulado pelo seu proponente, com o acréscimo da citada emenda apresentada pela Senadora sul-matogrossense.

Contudo, o Parecer (SF) nº 141/2017, ao ser publicado no Diário do Senado Federal (15), certamente por algum lapso, não trouxe em seu texto o dispositivo que constava na proposta aprovada e que previa, conforme já foi dito, a revogação do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Aqui, aparentemente, repousa o ponto nodal de toda a celeuma, qual seja, o descompasso entre o que foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e o texto publicado no Senado Federal, que, repita-se, não retratou aquilo que foi deliberado.

Fato é que, na sequência, o PLS 149/2015 foi encaminhado à CORELE (Comissão de Redação Legislativa), que, ao que consta, recebeu o texto, precisamente, como aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, isto é, contendo o dispositivo que revogava a majorante que tratava do emprego de violência ou ameaça exercida com emprego de arma (lato sensu) (16).

Posteriormente, o texto aprovado (17), que continha a revogação da majorante, e, porquanto, tal qual, efetivamente, deliberado pelo Senado Federal, foi encaminhado à Câmara dos Deputados, onde foi convertido no PL 9.160/2017, ao qual se apensou o PL 5.989/2016, de autoria do Deputado Severino Ninho, que já trazia apensado o PL 6.737/2016, que veiculava uma outra proposta legislativa que foi, então, acrescida à proposta vinda da Casa da Federação (18).

Mais à frente, o Plenário da Câmara dos Deputados, aprovou o Projeto de Lei tal qual encaminhado pelo Senado Federal, acrescido, apenas, de um artigo que dispôs acerca da inutilização de cédulas de moeda corrente depositadas no interior dos caixas eletrônicos em caso de arrombamento (19). Isto quer dizer que a única alteração material feita pela Câmara dos Deputados nada disse respeito à revogação da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Aliás, a derrogação da aludida causa de aumento de pena, constante na proposta vinda do Senado de República, manteve-se intocável, e restou prevista no artigo 4º do PL 9.160/2017, aprovado pela Casa Revisora.

Em seguida, no dia 06/03/2018, o Projeto de Lei – que, naturalmente, continha a revogação da majorante em seu artigo 4º – sob a rubrica de Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 1, de 2018, ao PLS nº 149, de 2015, retornou à Casa Iniciadora (20) onde foi aprovado pelo Plenário²¹.

Empos, como de rigor, encaminhou-se o texto aprovado para a sanção do Presidente da República, sendo que, posteriormente, houve a promulgação da lei aprovada²².

Como se pode ver, a revogação da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I,

do Código Penal, além de constar no texto original do PLS 149/2015, permaneceu no Texto Final aprovado pela CCJ no Senado Federal, depois, constou no PL 9.160/2017 aprovado pela Câmara dos Deputados, bem como no Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 1, de 2018, ao PLS nº 149, de 2015, aprovado, em sua integralidade, pelo Senado Federal.

Portanto, à guisa de conclusão, impõe-se reconhecer que a apontada inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018 se baseia num equívoco cometido na publicação do PLS 149/2015 no Diário do Senado Federal que, como visto, não guardou fidelidade com aquilo que, efetivamente, foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Tal equívoco, que há de merecer o timbre de mera irregularidade, não tem o condão de viciar o processo legislativo, ao ponto de se ter como inconstitucional o sobredito preceito. A propósito, é de ver que a mens legislatoris desde sempre, foi no sentido de revogar a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal e tal desiderato, ao final e ao cabo, foi alcançado com a promulgação da Lei 13.654/2018.

Convém registrar, por último, que, apesar de não conter qualquer vício de constitucionalidade formal, o artigo 4º da Lei 13.654/2018, representa, inequivocamente, grave redução no nível de proteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal, pois, afinal, a experiência aponta, ao sobejo, que o crime de roubo, comumente, é praticado tanto com armas de fogo, como também com o emprego de outras armas – próprias ou impróprias –, circunstância que, além de diminuir a possibilidade de reação da vítima, eleva a potencialidade da ameaça e da violência.

Assim, ante esse decréscimo do nível de proteção, abre-se a possibilidade de se questionar eventual violação do Princípio da Proporcionalidade na perspectiva da Proibição de Proteção Deficiente. Mas, claro, esse é um outro lado da moeda e, porquanto, há de ser discutido oportunamente.

Domingos Sávio de Barros Arruda – Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Procurador de Justiça (MP/MT).

Victor Lucas Alvim – Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Oficial de Gabinete (MP/MT).

03.<https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.foro=990&processo.codigo=RI0046PXE00000#?cdDocumento=35> . Acesso em 16 maio 2018.

04.<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Recomendacoes/COMUNICADO%20CAOCrim%20AVISO%20162%202018.docx> . Acesso em 16 maio 2018.

05.<https://www.mpms.mp.br/noticias/2018/05/procurador-geral-de-justica-do-mpms-aponta-inconstitucionalidade-em-lei-que-extingue-majorante-de-roubo-com-arma> . Acesso em 16 maio 2018.

06.<http://www.mpggo.mp.br/portal/noticia/nota-tecnica-do-mp-alerta-para-vicios-em-artigo-de-lei-que-altera-punicao-de-crime-com-uso-de-explosivo#.WwMXg-7RWM8> . Acesso em 21 maio 2018.

07.<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/120274> . Acesso em 16 maio 2018.

08.<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2163149> . Acesso em 16 maio 2018.

09. O arquivo pode ser baixado neste link: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-etter/documento?dm=3599802&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

10. O arquivo pode ser baixado neste link:

<https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=3599811&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

11. Trata-se da 37ª Reunião Ordinária da CCJ, cujo vídeo pode ser visto neste link:

<https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?5&reuniao=6590&codcol=34> . Acesso em 17 maio 2018. Conferir 01h37min15seg até 01h40min43seg do vídeo.

12. O arquivo pode ser encontrado no seguinte link:

<https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7267047&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

13. Trata-se da 49ª Reunião Ordinária da CCJ, cujo vídeo pode ser visto neste link:

<https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?0&reuniao=6919&codcol=34> . Acesso em 17 maio 2018. Conferir 01h00min até 01h18min do vídeo.

14. No website do Senado Federal, na seção “Tramitação” do PLS 149/2015, na aba do dia 08/11/2017, pode-se fazer o download do Parecer (SF) Nº 141, de 2017, no qual se tem o Parecer do relator, a Emenda aditiva, o Relatório de Registro de Presença da CCJ naquela data, a Lista de Votação Nominal, o Texto Final aprovado e a Decisão da Comissão. Conferir o seguinte

link:<https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7267047&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

15. O Parecer (SF) Nº 141, de 2017, quando publicado no Diário do Senado Federal do dia 10/11/2017 (páginas 133 a 143) não trouxe, no Texto Final aprovado pela CCJ, o dispositivo revogador da malfadada majorante (conferir, designadamente, as páginas 141 e 142). O Diário Oficial do Senado do dia 10 de novembro de 2017 pode ser baixado no seguinte link: <http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=10/11/2017&paginaDireta=00133#> . Acesso em 16 maio 2018.

16. Este órgão, ao que tudo indica, recebeu o texto que consta no site do Senado Federal, na seção de “Tramitação” do PLS 149/2015, na aba do dia 08/11/2017, ou seja, o texto com a revogação da majorante, efetivamente aprovado pelos parlamentares. Conferir: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7267047&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

17. <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7275778&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

18. O projeto apensado previa “que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que colocarem a disposição do público caixas eletrônicos, instalem equipamentos que inutilizem as cédulas de moeda corrente depositadas no interior das máquinas em caso de arrombamento, movimento brusco, alta temperatura, e dá outras providências”. Conferir: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2121517> . Acesso em 16 maio 2018.

19. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados pode ser baixado no seguinte link:

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1642561&filename=Tramitacao-PL+9160/2017 . Acesso em 16 maio 2018.

20. <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/132413> . Acesso em 16 maio 2018.

21. Nessa ocasião, a aprovação se deu após a leitura de parecer favorável da lavra do Senador Dário Berger (Parecer nº 51, de 2018 – PLEN/SF, em substituição à CCJ). O parecer pode ser baixado neste link:

<https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7652589&disposition=inline> .

Acesso em 16 maio 2018. O texto final aprovado pode ser baixado neste link:
<https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7653672&disposition=inline> .
Acesso em 16 maio 2018.

22. O texto pode ser baixado no seguinte link:
<https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7653672&disposition=inline> .
Acesso em 16 maio 2018.”

É o que ocorre quando analfabetos funcionais se metem a fazer e/ou alterar leis em nosso país.

Procede, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhe a pena.

Verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, considerando os maus antecedentes do acusado, envolvido com a criminalidade desde menor, tendo praticado ato infracional equiparado a roubo, bem como sua personalidade deformada, que o leva a reiteradamente violar a Lei, fixo a pena base além do mínimo legal, em 05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Observe-se que o conceito de maus antecedentes não se confunde com o de primariedade, que diz respeito à ausência de condenação transitada em julgado, sendo certo que para a configuração dos maus antecedentes basta que se verifique a participação do agente em práticas outras que se mostrem repreensíveis.

Face às atenuantes da confissão e da menoridade, retorno as penas ao patamar mínimo legal.

Em se tratando de roubo agravado (emprego de arma de fogo), o aumento médio da reprimenda deve ser de 2/3 sobre a pena fixada anteriormente, totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Em decorrência de tentativa, considerando-se que o delito não se aproximou de sua consumação (tentativa imperfeita), diminuo a pena em dois terços, totalizando definitiva em 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 05 dias-multa.

A pena pecuniária será calculada em patamar mínimo, ante a falta de elementos para inferir melhores condições econômicas do réu.

Nos termos do art. 59, c.c. os artigos 311, 312 e 387, parágrafo único, do Estatuto Adjetivo, considerando a extrema gravidade do ilícito praticado (em via pública, a mão armada, com ajuda um comparsa), que é daqueles que mais atingem e intranquilizam as populações ordeiras, notadamente nesta Comarca, onde já se tornou verdadeiro flagelo de proporções alarmantes, portanto a merecer repressão exemplar, deixo de lhe conceder quaisquer benefícios, inclusive o de recorrer em liberdade, devendo iniciar o cumprimento da pena corporal em regime fechado, o mais compatível com sua periculosidade e forma de proceder.

A fixação de regime mais brando ao acusado seria desproporcional à conduta, desprestigiaria a Justiça e não atingiria o fim colimado pela pena aplicada (art. 33, parágrafo 3º, CP).

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (CÓDIGO PENAL, ART. 157, § 2º, I E II). FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO . A alegação de que o regime prisional mais gravoso foi fixado com base na gravidade em abstrato do crime não encontra fundamento, pois as circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos réus, o que, inclusive, motivou o aumento da pena-base. Inteligência do art. 33, § 3º, c/c o art. 59, caput e inciso III, ambos do Código Penal. Ordem denegada. (Supremo Tribunal Federal - DESCRIÇÃO: HABEAS CORPUS - NÚMERO: 88493 - JULGAMENTO: 30/05/2006)

"O regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de réu primário. "Habeas corpus" indeferido. (Supremo Tribunal Federal - DESCRIÇÃO: HABEAS CORPUS - NÚMERO: 74301 - ACÓRDÃO MESMO SENTIDO: HC 68988 ANO-1991 UF-SP TURMA-02 N. PP-012 Min. MARCO AURÉLIO DJ 24-09-1999 PP-00026 EMENT VOL-01964-01 PP-00202 RAC-MIN-CARLOS VELLOSO - JULGAMENTO: 29/10/1996)

Inconcebível a aplicação da Lei n. 12.736/12, pois o instituto da detração e consequente progressão de regime não são automáticos e dependem do mérito do condenado (conduta carcerária e exame criminológico, se necessário) que, no caso do réu, não são do conhecimento deste Juízo e guardam pertinência com o Juízo das Execuções Criminais.

Com efeito, novamente foi publicada lei que visa ao esvaziamento das prisões sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que não pode conviver com criminosos precocemente soltos.

O condenado deverá pagar, ainda, ao final da execução, a taxa judiciária correspondente a 100 (cem) UFESP's, por força do art. 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual n. 11.608/03. Eventual exigibilidade deve ser aferida quando da execução.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno ALISSON PEREIRA LISBOA, já qualificado, por incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, cc art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir em estabelecimento adequado a pena de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 05 dias-multa, calculado o valor unitário da pena pecuniária no mínimo.

Desde já, providencie-se:

I - recomendação do condenado na prisão onde está.

Após o trânsito em julgado, providencie-se:

I - remessa de cópia desta decisão à vítima, com endereço nos autos;

II - lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados e, a seguir, solicite-se ao Juízo da Corregedoria dos Presídios a imediata transferência do mesmo para o regime prisional imposto;

III - comunicação desta decisão ao IIRGD e ao Instituto de Identificação de São Paulo.

P.R.I.C.